

1500696-75.2022.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... apreendido se destinava ao tráfico.

Nos termos da denúncia, por derradeiro, consta que o tráfico foi realizado mediante emprego de arma de fogo.

Eis, em compêndio, os termos da denúncia (fls.140/144).

A denúncia foi recebida, no dia 03 de junho de 2022 (fls.147/149).

Em momento ulterior, devidamente citado (fls.177), cõscio dos termos da denúncia, por intermédio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

1ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500696-75.2022.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500696-75.2022.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122801/2022 - 01º D.P. JALES, 24776860 - 01º D.P. JALES, 2122801 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FERNANDES DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ANTONIO CAMARGO DANTAS

Vistos.

RAFAEL FERNANDES DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso IV (emprego de arma), da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, c.c art. 69 do Código Penal (concurso material), porquanto, em conformidade com os termos vertidos na exordial acusatória, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 11 horas, na Rua José Neres dos Santos, 3090, Jardim São Judas Tadeu, na cidade e

comarca de Jales, o réu trazia consigo e guardava 02 (duas) porções de “maconha” (Cannabis S.L), tipo tijolos, com peso bruto total de 870,34 gramas, todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, com emprego de arma de fogo.

Segundo os termos vazados na incoativa, na mesma data, horário e local, o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da residência, um revólver usado, sem numeração, em razão do decurso do tempo, da marca “Orbea Hermanos”, calibre 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Colhe-se, ainda, da prefacial acusatória, que, na data dos fatos, policiais civis da DISE realizavam diligências de combate ao tráfico de entorpecentes no bairro São Judas Tadeu, e, por sua vez, para impedir o reconhecimento das viaturas, os agentes policiais realizaram diligências à paisana e a pé.

Perlustra-se, outrossim, da peça incoativa, que, sem ter conhecimento que se tratava de um policial, o réu interpelou um dos agentes que passava defronte ao seu imóvel, indagando-o se era o responsável pela retirada da “caminhada”.

Nos termos da incoativa, diante da expressão empregada (comum no meio da traficância), o policial respondeu afirmativamente e acionou, pelo celular, outros companheiros de diligência.

Consta, ainda, da prefacial, que, em seguida, ingressaram no imóvel, e, na parte frontal, encontraram uma porção grande de maconha (tipo tijolo) próxima ao réu.

Colhe-se, outrossim, da incoativa, que, durante a diligência, constataram que o réu guardava, em um quarto da casa, mais uma porção de maconha dentro de uma bolsa azul, juntamente com uma balança de precisão, e, outrossim, que ele mantinha, sob a sua guarda, um revólver, que foi localizado no interior de uma gaveta do seu guarda-roupas.

Divisa-se, em adição, da peça acusatória, que as circunstâncias da diligência (notadamente a oferta do próprio réu ao policial que transitava na via pública), a apreensão de grande quantidade de entorpecente (maconha), junto com uma balança de precisão, e, por fim, a apreensão de arma de fogo, revelaram que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico.

Nos termos da denúncia, por derradeiro, consta que o tráfico foi realizado mediante emprego de arma de fogo.

Eis, em compêndio, os termos da denúncia (fls.140/144).

A denúncia foi recebida, no dia 03 de junho de 2022 (fls.147/149).

Em momento ulterior, devidamente citado (fls.177), còncio dos termos da denúncia, por intermédio de sua defensora apresentou a abalizada defesa escrita (fls.174/175).

A despeito do esmero da defensora, à míngua dos elementos de convicção necessários, arredou-se a possibilidade da absolvição sumária (fls.181/184), designando-se, na oportunidade, audiência de instrução, debates e julgamento (fls.197).

Durante a instrução processual houve a colheita da prova oral, ouvindo-se, por conseguinte, três testemunhas, como, também, o réu, o qual, em sede de interrogatório, exerceu a sua autodefesa (fls.243/245).

Ao cobro da instrução, primeiramente, como sói ocorrer, manifestou-se o Ministério Público, na lavra de seu Ilustre Promotor de Justiça, o qual, em sua faina, pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, averbando, no ponto, a comprovação da

materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls.27/29), auto de exibição e apreensão (fls.31/32), laudo de constatação (fls.40/43), rebatimento fotográfico (fls.48/49), laudo de exame químico-toxicológico (fls.80/82), laudo pericial (fls.83/88), que constatou a eficácia da arma, laudos periciais (fls. 89/93, 94/98 e 102/107), bem como pela prova oral coligida em audiência, e, ainda, da autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado.

Sublinhou, outrossim, que, na sua ótica, o manancial probatório comprovou que o acusado tinha consigo e guardava a droga que foi apreendida nos autos e que o entorpecente se destinava ao tráfico, pontuando, ainda, que, embora não tenha sido pilhado no ato de efetiva mercancia, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 possui tipo de conteúdo variado, averbando, a seu turno, que o simples ato de guardar a droga para efeito de tráfico, ainda que realizado por terceiro, caracteriza o delito.

Salientou, ainda, que houve a apreensão de uma balança de precisão com o acusado, sendo este objeto utilizado na separação da droga em pequenas porções, para serem comercializadas.

Asseverou, outrossim, que o réu não negou a posse dos entorpecentes, afirmando que recebeu a maconha de uma terceira pessoa, para quem devia dinheiro, como forma de saldar sua dívida de droga, demonstrando que o réu tinha ciência de que a droga seria comercializada.

Pontuou, por sua vez, que não se sustenta a alegação de que o réu estava fazendo tratativas com os policiais, o que ensejaria um flagrante preparado, não existindo nos autos qualquer comprovação de suas alegações, afirmando, ainda, que a consumação do crime ocorreu quando o réu aceitou a guarda da droga, no dia anterior.

Averbou, ainda, que, em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2006, deve haver condenação, considerando, a sua vez, que, embora a arma não estivesse municiada, a posição jurisprudencial pacífica é no sentido de que o crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, de maneira que é desnecessária qualquer incursão quanto a uma suposta ofensa ao bem jurídico tutelado, sendo irrelevante o fato de a arma estar ou não acompanhadas de munições.

Ao incursionar sobre a dosimetria da pena, no que alude à pena base, apontou a existência de maus antecedentes do réu, pugnando pelo recrudesimento da pena, tendo sido condenado nos autos nº 0001309-53.2014.8.26.0297. Na segunda fase, pugnou, no ponto, pelo reconhecimento da agravante da reincidência, pontuando, a sua vez, que o réu foi condenado nos autos nº 0006106-38.2015.8.26.0297. De sua vez, na terceira fase, manifestou-se pela presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, sublinhando, outrossim, a impossibilidade da incidência da redutora prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão de o réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes. Em linha de remate, em razão das duas condutas distintas perpetradas, pugnou pela aplicação da regra contida no art. 69 do Código Penal, e, por sua vez, propugnou pela fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando, a seu turno, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. Por derradeiro, requereu o perdimento dos objetos apreendidos (fls.232/241).

A defesa, por seu turno, averbou, em apertada síntese, que o réu sempre teve emprego fixo, e, por sua vez, que não possui maus antecedentes.

Pontuou, em adição, que a conduta social do acusado também se mostra favorável, podendo ser considerado réu primário, apontando, outrossim, que o réu foi apenas autuado em crime de menor potencial ofensivo, que tramitou no JECRIM da Comarca de

Jales.

Asseverou, outrossim, que o réu não possui personalidade voltada para o crime, e, por sua vez, que o réu não era conhecido nos meios policiais, e, ainda, que o réu tinha bom comportamento no seu serviço, tendo um emprego garantido.

Brandiu, por sua vez, que o réu manteve a mesma versão, coesa e tangível, tendo a sua conduta se limitado a ser “mula” para a guarda do entorpecente, com a finalidade de auferir certa quantia em dinheiro nesta empreitada.

Averbou, a seu turno, que inexistem provas de que o réu se dedicava ao tráfico com habitualidade, sendo réu primário e não possuindo maus antecedentes, averbando, ainda, que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas não são indicativos da dedicação ao tráfico.

Salientou, de sua vez, que o réu confessou a prática do delito, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, averbando, ainda, que o réu estava atravessando por problemas financeiros.

Aduziu, ainda, que não deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, consignando, a seu turno, que, em momento algum, a arma foi utilizada.

Apontou, a seu turno, que a quantidade de droga apreendida não é capaz de afastar a aplicação da redução da pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, pugnando, por sua vez, pela aplicação da referida redutora em seu patamar máximo.

Pugnou, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com imposição do regime inicial aberto, em caso de descumprimento (fls.250/256).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece ser parcialmente agasalhada.

Nessa ordem de ideias, de se ver que, a testemunha Eduardo Pereira Missias, ao prestar seu depoimento em pretório, disse que, na data do fato, tiveram a informação de uma entrega de drogas próximo ao “Bar do Branco”, na Rua Dezenove, informando, ainda, que se deslocou a pé até a localidade, a fim de observar a movimentação, informando, outrossim, que a viatura da polícia já era conhecida na cidade. Narrou, a seu turno, que, ao passar pela casa do réu, foi questionado pelo réu se seria o responsável por buscar a “caminhada”, informando, a sua vez, que conhecia o referido termo como droga, ao que respondeu ao réu que era a pessoa designada pelo recebimento da droga. Relatou, ainda, que o réu franqueou a sua entrada no imóvel, informando, a sua vez, que estava com a equipe policial sob alerta, estando com o celular em mãos, afirmando, em adição, que já havia indicado o local à equipe policial, a qual o acompanhava visualmente. Disse, em acréscimo, que a equipe policial já tinha se aproximado do imóvel, informando, outrossim, que, no momento em que o réu abriu o portão da sua casa, já havia um pedaço de droga próximo ao réu, no solo, a qual foi apreendida. Afirmou, ainda, que a equipe policial reconheceu as características da substância apreendida como droga, e, por sua vez, que fizeram a prisão em flagrante do réu. Narrou, a seu turno, em diligências no interior do imóvel, que foi encontrada uma bolsa azul, contendo outro pedaço de droga e uma balança, e, ainda, que, dentro do guarda-roupas, havia uma arma, calibre 32, apta ao disparo, segundo informações da perícia. Afirmou, a sua vez, que, na ocasião, o réu assumiu a propriedade da droga, e, ainda, que o réu indicou a sua localização no imóvel. Confirmou, ainda, que trabalha na DISE, informando, por sua vez, que o réu não era um alvo de investigação, e, a seu turno,

que não tinham conhecimento de quem faria a entrega da droga, quando receberam as informações. Informou, em acréscimo, que o réu possuía uma passagem pela polícia ou uma condenação por tráfico de drogas, negando, a seu turno, que existissem informações junto à DISE referentes ao réu. Disse, a sua vez, que as informações recebidas foram anônimas, informando, a seu turno, que, em algumas vezes, essas informações não são detalhadas, não sendo direcionadas a pessoas ou nomes específicos, informando, outrossim, que tinham informações da localidade e de que haveria uma entrega de drogas. Disse, ainda, que não se recorda da forma como a informação anônima chegou ao seu conhecimento, informando, a seu turno, que também procura resguardar as fontes de informação da investigação, afirmando, ainda, que as informações chegaram pela sua equipe. Disse, outrossim, que, na data do fato, não se recorda de ter ocorrido a prisão de outra pessoa, antes da prisão do réu. Afirmou, ainda, que o réu não era pessoa conhecida pela DISE. Informou, ainda, que houve um flagrante do réu por tráfico de drogas, e, por sua vez, que não se recorda se houve a sua conversão em prisão preventiva, informando, outrossim, que não se recorda essa prisão se deu no passado ou atualmente. Afirmou, a seu turno, que, na data do fato, o réu assumiu a propriedade da arma de fogo, afirmando, ainda, que a família do réu estava presente no local, e, outrossim, que acredita que o réu tenha assumido a propriedade da arma de fogo para que a responsabilidade deste fato não recaísse sobre outra pessoa. Disse, em adição, que a esposa do réu estava presente no quarto. Informou, ainda, que o réu não declarou o motivo pelo qual estava na posse de uma arma de fogo, e, a seu turno, que, na ocasião, a arma não estava municada. Disse, em acréscimo, que as munições estavam juntas da arma, mas não municadas, não estando prontas para disparo, informando, ainda, que a arma era apta ao disparo. Informou, ainda, que não se recorda ao certo, mas que acredita que foram apreendidas munições, informando, outrossim, que apenas se ateve às questões envolvendo as drogas.

A testemunha Paulo Henrique Garcia, de sua vez, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que, na data do fato, tinham a informação de que um indivíduo, na vizinhança do local do fato, faria a entrega de uma droga, informando, outrossim, que não sabiam o local exato, tendo apenas a informação de que seria próximo ao "Bar do Branco". Relatou, a seu turno, que o policial Eduardo era menos conhecido na região e foi a pé ao local do fato, e, por sua vez, que ficaram a uma certa distância com a viatura descaracterizada. Narrou, ainda, que, ao passar pelo imóvel do réu, o policial Eduardo foi abordado pelo réu, questionando-o se seria o responsável por buscar a "caminhada", ao que o policial Eduardo respondeu positivamente. Informou, a sua vez, que o termo "caminhada", nos meios policiais, refere-se à droga. Relatou, ainda, que o policial foi convidado pelo réu a entrar na varanda da casa dele, informando, outrossim, que o policial estava na posse de um aparelho celular, tendo enviado mensagem aos policiais. Disse, em acréscimo, que foram até a residência do réu e ingressaram no imóvel, no momento em que o réu havia pegado o entorpecente, que estava próximo dele, para efetuar a entrega ao policial Eduardo. Relatou, em adição, que o réu estava com o entorpecente na mão, quando deram voz de prisão, afirmando, ainda, que o réu ofereceu certa resistência, sendo algemado. Disse, ainda, que conduziram o réu para o interior do imóvel, quando localizaram, em um quarto, uma bolsa azul, contendo um pedaço de tijolo de droga e uma balança de precisão, afirmando, outrossim, que, em outro quarto, houve o encontro de uma arma de fogo. Relatou, por sua vez, que, na ocasião, o réu se declarou usuário de drogas e que estava precisando de dinheiro, tendo aceitado a proposta de uma terceira pessoa para a venda do entorpecente. Disse, em adição, que o réu declarou que faria a venda do entorpecente, e, por sua vez, que ele não declinou o destinatário, informando, ainda, que o réu declarou que a sua motivação foi o levantamento de recursos financeiros. Afirmou, outrossim, que o réu havia declarado que a arma seria igualmente destinada à venda. Disse, a sua vez, que, salvo seu engano, a arma não estava municada. Afirmou, ainda, que a denúncia anônima não mencionava um nome, informando, outrossim, que o réu não era conhecido nos meios policiais, e, por sua vez, que apenas tinham conhecimento da sua prisão por tráfico de drogas em 2018. Disse, a seu turno, que, no momento da abordagem, o réu

apresentou certa resistência, informando, ainda, que, posteriormente, o réu acompanhou a revista realizada em seu imóvel. Disse, em adição, que, inicialmente, o réu ofereceu certa resistência durante a sua abordagem, e, por sua vez, que foi necessário o uso de algemas, negando, a seu turno, que tivesse ocorrido agressão por alguma das partes. Disse, ainda, que receberam a denúncia anônima de maneira informal, informando, em acréscimo, que são pessoas que os procuram para denunciar alguns fatos que ocorrem, e, outrossim, que não formalizaram o registro desta denúncia, em razão da proximidade dos acontecimentos.

A testemunha Roger Aparecido da Silva Furusho, a seu turno, ao prestar seu depoimento em juízo, disse que já foi companheiro de trabalho do réu, sendo responsável pelas pessoas que trabalhavam por diária. Disse, ainda, que trabalhavam com frutas e legumes. Afirmou, a seu turno, que o réu sempre cumpria o seu horário de trabalho, e, por sua vez, que não tinham um horário fixo, por conta da atividade relacionada aos alimentos. Disse, em adição, que houve situação de o réu acompanhá-lo durante à noite para realizar um carregamento, informando, outrossim, que o réu nunca reclamou desta situação. Relatou, ainda, que contrataria o réu novamente, caso ele seja solto, informando, a seu turno, que a equipe de trabalho ficou sentida pelos acontecimentos, considerando, a sua vez, que o réu era uma boa pessoa e que era trabalhadora. Informou, a seu turno, que o réu trabalhou em sua companhia durante bastante tempo, e, ainda, que ele trabalhou até antes da sua prisão, informando, outrossim, que o réu tinha trabalhado até uma semana antes, em virtude da ausência de demanda.

O réu Rafael Fernandes de Lima, por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, disse que tem 28 anos de idade e que estava morando com a esposa e a filha. Relatou, ainda, que trabalhava na empresa de frutas e legumes do Roger, tendo trabalhado durante todo o período de gravidez da sua esposa, informando, outrossim, que estava sobrecarregado de serviço, não tendo horário para retornar para casa. Disse, a seu turno, que também tinha se afastado por certo tempo do serviço para cuidar da esposa, passando a fazer trabalhos autônomos como pintor e servente, por dia. Confirmou, a sua vez, que, na data do fato, abordou uma pessoa, a qual se identificou, posteriormente, como policial, questionando-a se era a pessoa responsável pela retirada de uma "caminhada". Narrou, a seu turno, que estava fazendo trabalhos autônomos como pintor, e, por sua vez, que o seu aluguel estava atrasado e a sua filha estava com cinco meses de vida. Disse, ainda, que também houve o atraso no pagamento da água e da luz, além do aluguel, informando, a seu turno, que, nessa ocasião, surgiu a malfadada proposta em sua vida, que consistia em tomar a posse da droga para transferi-la a outrem. Negou, a seu turno, que houvesse o propósito de revenda da droga. Narrou, por sua vez, que obteve a droga em uma quarta-feira, a qual seria levada no mesmo dia, à noite, informando, outrossim, que, por algum motivo, a droga não foi levada na quarta-feira, à noite, ficando para buscarem a droga na quinta-feira, pela manhã, e, ainda, que este foi o dia da sua apreensão. Relatou, ainda, que, na quinta-feira, de manhã, recebeu mensagem pelo whatsapp, perguntando sua localização para a retirada da droga, informando, outrossim, que negociou o local para a retirada da sacola. Afirmou, a sua vez, que não tinha percebido que estava falando diretamente com a polícia, afirmando, ainda, que, inclusive, perguntou ao policial se ele era o responsável pelo recebimento da droga. Negou, a seu turno, que tivesse sido orientado sobre o tipo de entorpecente que estava recebendo, afirmando, ainda, que apenas recebeu uma bolsa. Afirmou, em adição, que, posteriormente, abriu a sacola e verificou que havia maconha e um revólver dentro dessa bolsa. Confirmou, a sua vez, que tinha conhecimento de que estava recebendo uma arma de fogo junto da mochila. Relatou, ainda, que, antes do seu casamento, já devia uma certa quantia em dinheiro, quando foi procurado pela pessoa que lhe apresentou a proposta envolvendo o entorpecente, sob a promessa de que, para além da dívida, ainda ficaria com certa quantia. Disse, a seu turno, que aceitou a malfadada proposta. Confirmou, ainda, que era usuário de drogas e que a dívida decorria da aquisição de drogas. Informou, a sua vez, que a balança veio junto da mochila recebida. Confirmou, ainda, que as tratativas eram

feitas por telefone, por meio do aplicativo whatsapp. Negou, a seu turno, que a pessoa com quem tratava do recebimento da droga fosse a mesma que lhe tinha fornecido o entorpecente. Informou, ainda, que tinha recebido o número de telefone daquele que lhe entregou o entorpecente, e, por sua vez, que foi informado de que o seu número seria repassado para um terceiro, que faria a retirada da droga. Disse, a sua vez, que, em seguida, houve a sua prisão, tendo entregado a droga para a polícia, sem que tivesse conhecimento disto. Confirmou, a seu turno, que, em verdade, era a polícia que estava conversando com a sua pessoa pelo whatsapp, confirmando, ainda, que houve uma preparação para que os policiais chegassem até a sua casa.

De sua vez, os parágrafos encimados espelham os contornos da prova oral.

De partida, merece averbação, por ocupar praça relevante, que, em absoluto, o caso em apreço, espelha hipótese de flagrante preparado, porquanto quando da ação policial, a rigor, o réu já guardava a droga em sua casa, não havendo, assim, qualquer intervenção dos agentes policiais.

Noutros dizeres, os agentes policiais não instigaram o réu a guardar a droga em sua casa, de tal arte que, quando da abordagem, tratando-se de crime permanente, a bem da verdade, o réu já se encontrava em estado de flagrância pela guarda da droga apreendida.

A rigor, o delito de tráfico consuma-se com a prática de qualquer uma das ações nucleares inculpidas no artigo 33 da Lei de Drogas, de sorte que, sendo a ação de guardar precedente à ação policial, notadamente ao considerarmos que dita conduta acena para o crime permanente, diante do estado de flagrância, para além da lisura da atuação policial, não se cogita, em absoluto, da configuração do flagrante preparado.

Nessa ordem de ideias, perlustra-se, no caso em tablado, que, a bem da verdade, não houve qualquer participação direta ou indireta dos policiais, como indução, instigação, ou preparação, que pudesse influenciar a prática delitiva do réu antes da sua prisão em flagrante.

Assentadas estas linhas propedêuticas, doravante, analisaremos as condutas imputadas ao réu, à luz do acervo probatório existente nos autos.

De início, no que concerne ao crime de tráfico de drogas, a materialidade do delito é incontestes, porquanto, devidamente ancorada no auto de prisão em flagrante (fls.01), boletim de ocorrência (fls.27/29), auto de exibição e apreensão (fls.31/32), laudo de constatação (fls.40/43), rebatimentos fotográficos (fls.48/49), laudo de exame químico-toxicológico (fls.80/82) e laudos periciais (fls. 89/93 e 94/98).

No mesmo trilho, não grassa qualquer dúvida acerca da autoria, na medida em que, para além da droga ter sido apreendida, no interior da casa do réu, este ao ser ouvido, sem tergiversar, reconheceu a guarda da droga, bem como da arma de fogo.

Outrossim, de se gizar, por oportuno, que o réu, em momento algum, se disse insciente acerca do objeto que estava guardando, ao reverso, asseverou, sem rebuças, que era cômico do fato de estar guardando droga, bem como da existência da arma de fogo.

Por sua vez, a corroborar a confissão do réu, despontou os depoimentos coesos, lúcidos e claros das testemunhas.

Com efeito, conforme se extrai dos autos os depoimentos das testemunhas foram coesos em nada disformes, mostrando-se assaz contundentes para suportar a realidade da traficância.

Conforme já salientamos em outros sítios, a nosso juízo, por um imperativo lógico, os depoimentos dimanados de policiais não podem ter valor absoluto.

De fato, ao vingar o entendimento do valor absoluto do depoimento proferido de policiais, a rigor, diversos princípios constitucionais estariam malferidos.

A rigor, seria desnecessário o devido processo legal, porquanto as asserções provenientes de policiais seriam suficientes ao édito condenatório, desconsiderando-se, por seu turno, qualquer outro meio de prova, sacramentando-se o sistema tarifário de provas, não adotado em nosso ordenamento.

Demais disso, restaria malferido o princípio da presunção da inocência, invertendo-se completamente o ônus da prova, porquanto enunciado determinado fato penal por determinado policial, caberia ao réu demonstrar que o fato não teria ocorrido como dito, atribuindo-lhe, assim, o ônus de provar a sua inocência, em rematada afronta à Constituição da República.

Todavia, no caso em tablado, os depoimentos dos policiais não se encontram isolados, ao reverso, estão em consonância com o material probatório.

Os depoimentos dos policiais despontaram como coesos e seguros.

Por sua vez, para além da sua prisão em flagrante, o réu, em pretório, confessou a guarda dos entorpecentes em favor de terceira pessoa, declarando, a seu turno, que aceitou a proposta de guarda dos entorpecentes, porquanto enfrentando problemas financeiros, estando com os pagamentos do aluguel, água e luz atrasados, salientando, ainda, que seria o responsável pelos cuidados de sua filha recém-nascida.

Nessa senda, não há qualquer disputa acerca da autoria.

No mesmo toar, dúvida não padece no sentido de que a droga era destinada à mercancia, não somente pela quantidade apreendida, absolutamente destoante do consumo pessoal, mas, sobretudo, em virtude do conteúdo do próprio interrogatório do réu, o qual evidenciou que guardou a droga, mediante contraprestação econômica, e que esta, por sua vez, seria entregue à terceira pessoa, o que, de forma estreme de dúvidas, corrobora o desígnio mercantil.

De outro bordo, no caso em tablado, não se cogita do reconhecimento da incidência da majorante preconizada no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, porquanto o predito inciso reclama o emprego de arma de fogo, o que, minimamente, exige o porte ostensivo relacionado com a traficância, não podendo ser compreendido, ou melhor, confundido, com a guarda da arma, no interior de um imóvel, a qual sequer estava junto ao corpo de seu possuidor.

Demais disso, para configuração da majorante, deve-se ter em linha de conta, por ocupar praça relevante, que a causa de aumento somente tem ensanchar quando, concretamente, o artefato é utilizado com o escopo de provocar, direta ou indiretamente, a intimidação.

Nessa senda, a majorante contida no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, não merece prosperar, haja vista que o texto legal exige, especificamente, o emprego da arma de fogo, de forma intimidatória à coletividade, para a prática do tráfico de drogas, o que não foi colhido da prova judicializada.

Demais disso, sob pena de patente bis in idem, não se cogita do reconhecimento da



majorante, se a denúncia imputa, concomitantemente, o crime de posse de arma de fogo.

De todo modo, no que toca à posse de arma de fogo, considerando-se as circunstâncias de sua apreensão, não divisamos cenário seguro ao seu reconhecimento, notadamente ao considerarmos os princípios constitucionais penais.

Com efeito, malgrado ser indisputável a sua localização (fls.31/32), não perλούstramos cenário compatível com o reconhecimento do crime preconizado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, porquanto conforme se infere dos autos, a bem da verdade, a arma de fogo se encontrava desmuniada, não havendo, outrossim, elementos cognitivos demonstrando o encontro de munições no local (fls.87/88 - itens 2 e 11).

Nessa linha de intelecção, não há qualquer halo de prova a denotar a perspectiva de pronto carregamento, o que importa dizer, não se vislumbra, no caso vertente, a perspectiva de pronto uso da arma de fogo.

Noutras letras, no contexto da apreensão da arma, nada há a indicar que haveria a possibilidade do seu pronto municiamento, na medida em que não foi possível divisar a existência de munições no local.

Interpretando-se a norma em conformidade com o bem jurídico protegido, a saber: a segurança pública, conclui-se, de forma heurística, que a arma de fogo desmuniada, sem qualquer perspectiva concreta de pronto uso de munição, desponta como engenho mecânico incapaz de lançar projéteis, de sorte que, não verificamos a possibilidade do reconhecimento de potencialidade lesiva e tipicidade material.

Em uma palavra, se não há risco de lesão ao bem jurídico protegido (segurança pública), justamente pela absoluta inaptidão da arma de fogo para o disparo, na medida em que não havia munições no local, não se cogita da configuração do crime em comento.

Deveras, estando o revólver desmuniado, a rigor, perde completamente a sua potencialidade lesiva, de tal arte que, em casos tais, somente é possível o reconhecimento da tipicidade formal, mas, em absoluto, da tipicidade material.

O bem jurídico protegido, a saber, a segurança pública, a rigor desponta como elemento limitador do alcance da norma, de molde que deve limitar o alcance e a interpretação do dispositivo criminalizador.

Nessa senda, o réu deve ser absolvido do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Por sua vez, do cotejo entre as fls. 54/66 dos autos, colhe-se, sem reбуças, quadra suficiente ao reconhecimento da reincidência (fls.54 - 0006106-38.2015.8.26.0297) e dos maus antecedentes (fls.54/55 - 0001309-53.2014.8.26.0297).

De todo modo, a despeito do registro que poderia ser sopesado como maus antecedentes, diante da redução da culpabilidade em virtude da situação de vulnerabilidade decorrente de circunstâncias que envolvem problemas socioeconômicos, os quais não foram confrontados pelo Ministério Público, tampouco defrontados por elementos de convicção contrários, razoável e proporcional que o aumento da pena se dê no patamar de 1/6, considerando-se, no ponto, a quantidade de droga apreendida.

Nessa senda, os maus antecedentes são compensados pela vulnerabilidade social, a reduzir, no ponto, o juízo de responsabilidade.

Com efeito, a versão do réu no sentido de que aquiesceu com a guarda da droga por

problemas econômicos, não sendo contrariada por provas em sentido contrário, não pode deixar de ser valorada, sob pena do esvaziamento do sentido do interrogatório, o qual, nada obstante ser predominante um meio de defesa, não perde o seu caráter probatório, sendo, por conseguinte, elemento de convicção a ser valorado em conjunto com os demais elementos que formam o acervo probatório.

Com efeito, a precariedade da situação econômica, iniludivelmente, repercute na tomada de decisões, influenciando, assim, no juízo da responsabilidade, porquanto, em certa medida, diante da caótica situação econômica, com repercussões severas nas vidas de esposa e filhos, não se concebe a possibilidade do reconhecimento da mesma dirigibilidade normativa, - possibilidade concreta de agir em conformidade com a norma.

A vulnerabilidade social, como, *verbi gratia*, baixo nível de instrução, desemprego ou subemprego, bem como a miserabilidade, indubitavelmente, reduzem o grau de responsabilização, de molde que são circunstâncias que devem ser sopesadas, na primeira fase do artigo 59 do Código Penal no que atine às circunstâncias judiciais.

De todo modo, considerando-se a quantidade de droga apreendida, mister a exasperação da pena, na primeira fase do sistema trifásico, no patamar de 1/6.

A seu turno, conquanto a reincidência plasmada na certidão de fls. 54 dos autos, arrede, de forma pontual, o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, o qual a rigor não se trata de tráfico privilegiado, mas, sim, de hipótese de redução de pena, devemos ter em consideração que ao ser considerada a reincidência para alijar a minorante, não deverá ser sopesada para fins de exasperação da pena, na fixação da pena provisória, na segunda fase do sistema trifásico, sob pena de indisputável *bis in idem*.

Com efeito, a dupla valoração da mesma circunstância para recrudescer a situação do réu, na fixação da pena, acaba por render azo ao *bis in idem*.

Nessa linha de inteligência, Paulo Queiroz preconiza a aplicação analógica da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, vazada nos seguintes termos: "A reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial". (Queiroz, Paulo. Comentários à Lei de Drogas, Editora JusPODIVM).

Colhe-se, outrossim, da dogmática abalizada o seguinte excerto: "Houve, portanto, *bis in idem*, porque a mesma circunstância incidiu, mais de uma vez, na individualização da pena, implicando, por duas vezes, um aumento da reprimenda, ora como agravante, ora como circunstância impeditiva da redução da pena. (...) Como vimos, sempre que tal ocorrer, deve predominar a circunstância que mais aumenta ou que mais diminua a pena, razão pela qual, no caso, há de prevalecer como causa impeditiva do privilégio (artigo 33, §4º, da Lei), sendo desprezada enquanto agravante legal". Queiroz, Paulo. Comentários à Lei de Drogas Editora JusPODIVM, p.55/56).

Nessa linha de inteligência, a reincidência, não deve ser duplamente valorada para fins de recrudesimento da situação do réu.

Averbo, ainda, no ponto, que o regime fechado, diante do cenário dessocializador do cárcere, que, como regra, somente serve à inocuização do ser humano, a rigor, deve ser reservado somente àqueles que praticam crimes timbrados pela violência à pessoa, notadamente aqueles matizados pela selvageria e a barbárie, ou, ainda, àqueles que estão enfronhados nas grandes organizações criminosas, diante da absoluta ausência de soluções mais adequadas para alguns casos.

Salvante tais cenários, sempre que possível, devem ser buscadas as penas alternativas, que, em essência, arredam os efeitos traumáticos e estigmatizantes do cárcere, os quais marcam, de forma deletéria e indelével a existência humana, sobretudo em razão do hiato existente entre o discurso da ressocialização e a realidade empírica e científica, ou, ainda, os regimes mais brandos, quando não preenchidos os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão da suspensão condicional da execução da pena.

De fato, a prisionização invariavelmente, conduz à aculturação prisional, com regras deletérias e próprias de sobrevivência, marcadas, amiúde, pela violência e a malandragem.

Com efeito, iniludivelmente, hodiernamente, a estrutura prisional não cumpre com a promessa de ressocialização do ser humano, de molde que, as funções da pena, em verdade, acabam se restringido a uma única função, a saber, prevenção especial negativa, no sentido de neutralização do ser humano.

Nessa senda, o regime fechado deve ser destinado àqueles que, realmente, precisam ser neutralizados sob pena de grave risco social.

Assim, a apropriação legal do tempo e do espaço de determinada pessoa, no regime fechado, revela-se medida excepcional, que, diante da ausência do cumprimento integral das funções da pena, não deve ser prodigalizada, restringindo-se a cenários excepcionais.

Em uma palavra, imperiosa a análise do Direito Penal, em conjunto com a Criminologia e a realidade social e prisional, sob pena de as operações alusivas à aplicação da pena ocorrerem como mero exercício de subsunção, estabelecendo-se um verdadeiro sistema autopoiético, impenetrável por outras ciências.

Como cediço, diante dos princípios constitucionais, notadamente os que dizem respeito à dignidade humana e proporcionalidade, diante de culpabilidade reduzida, nada há a interditar a fixação de regime mais brando, a despeito da reincidência.

Com efeito, colhe-se da letra do artigo 33, §3º, do Código Penal, que a determinação do regime inicial do cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios preconizados no artigo 59 do Código Penal, de molde que sendo a culpabilidade reduzida, haja vista que as circunstâncias judiciais foram predominantemente favoráveis, nada obstante a reincidência, nada há a empecer a fixação de regime mais brando do que o fechado, notadamente diante da ausência da reincidência específica.

Como corolário, mister concluir que o regime de pena deve ser fixado conforme a necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, observando-se, outrossim, a responsabilização penal - culpabilidade em sentido amplo.

Todavia, na quadra hodierna, a única função real e realizável, iniludivelmente, é a função de prevenção especial negativa, diante da absoluta incapacidade de ressocialização da pena de prisão, porquanto, a rigor, a prisionização enseja a dessocialização e a aculturação prisional.

Com efeito, como regra, o cárcere neutraliza e leva à inocuização do encarcerado.

Contudo, diante do ambiente absolutamente criminogênico da grande maioria dos estabelecimentos prisionais, e, notadamente, diante das deformações dimanadas da prisionização, em razão da aculturação prisional, com todos os seus consectários deletérios na vida pessoal, social e familiar dos presos, com forte comprometimento do futuro dos encarcerados e dos seus familiares, em virtude do inarredável

etiquetamento e do novo status jurídico adquirido, o encarceramento, na quadra atual, nos regimes mais estoicos, deve ser absolutamente excepcional, reservando-se, conforme gizado, aos crimes matizados pela barbárie e selvageria, ou quando as circunstâncias do contexto delinquencial sejam denotativas do grande risco da prática de crimes de grande envergadura em série, ou, ainda, quando desenhada a tessitura das grandes estruturas criminosas.

Tirante estes contextos, iniludivelmente, devem ser buscados os substitutivos penais, ou, os regimes mais brandos.

Conforme pontifica Salo de Carvalho: "(...) os critérios do §2º do artigo 33 se constituem, em realidade, como fronteira máxima da punibilidade. (...) A flexibilização da legalidade penal em benefício do réu, seguindo a previsão exposta no art.33, §2º, é plenamente possível em um modelo de garantias. O contrário, porém, é vedado, visto ser a legalidade uma barreira de contenção que não pode ser ultrapassada em prejuízo dos direitos individuais". Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro, p.468, Saraiva.

Neste eito, a pena e o regime de cumprimento deverão ser estabelecidos, em conformidade com o grau de responsabilidade penal (culpabilidade em sentido amplo) e o comportamento concretamente realizado, primando-se, assim, pela individualização da pena, proporcionalidade e dignidade humana

Por tais razões, respeitando-se, sempre, os entendimentos divergentes, forte na política de redução de danos, a nosso visto, hodiernamente, observando-se os princípios constitucionais, entre os quais se alistam a proibição de dupla incriminação, proporcionalidade, humanidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena, não havendo culpabilidade acentuada no sentido de responsabilização penal, sendo as circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, diante do reduzido grau de responsabilização penal, não se justifica a aplicação dos regimes mais gravosos, inclusive, no caso concreto, evitando-se, a desproporcionalidade, porquanto o registro ensejador do reconhecimento da reincidência já foi considerado para o afastamento da minorante, não se revelando proporcional que fatos extratípicos porquanto não alusivos à imputação versada nestes autos, repercutam, sucessivamente, em cadeia, agravando a situação do réu.

Nesse trilha, professam João Paulo Martinelli e Leonardo Schmitt de Bem que: "A reconsideração de uma circunstância já analisada para incidência em etapas posteriores ao término do processo de injunção penal, geralmente negativa ao condenado, é atentatória ao princípio do ne bis in idem. (Direito Penal lições fundamentais Parte Geral Editora D'PLÁCIDO).

Nessa ordem de ideias, forte no princípio da proporcionalidade, em casos tais, diante da reduzida culpabilidade, sem embargo da reincidência, não interdita a fixação de regime mais brando, a saber, o regime semiaberto.

Nesse sentido, a jurisprudência de alto coturno: "Não há por que dar ao réu que não demonstra possuir grau de culpa intensa, cuja personalidade e conduta não revelam traços de periculosidade ou temerabilidade social, o mesmo tratamento a quem é participante de criminalidade de alta periculosidade (STJ, REsp 196.940-DF, rel.Min. Vicente Cernicchiaro, DJU 17.5.99, RT 768/545). No caso em tela, a rigor, nada há a indicar o envolvimento do réu com a grande traficância.

Nessa ordem de ideias, considerando-se que os critérios inculpidos no §2º do artigo 33 do Código Penal despontam como parâmetros máximos de punibilidade, se as circunstâncias judiciais predominantemente forem favoráveis, nada interdita que, a despeito da reincidência, haja a fixação do regime intermediário.

Noutras letras, se as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis ao réu, dentro de uma ótica constitucional que valoriza os direitos fundamentais, o princípio da individualização da pena em seu espectro amplo, no sentido de se estabelecer uma resposta adequada e necessária, não justifica o estabelecimento de um regime mais estoico que não se mostra adequado ao nível de responsabilização penal demonstrado, no caso em tablado.

Nesse sentido, pontifica Salo de Carvalho: "Se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, não haveria quaisquer óbices para aplicação do regime semiaberto nos casos de (a) pena fixada acima dos oito anos ou de (b) sanção dosada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, em caso de réu reincidente; ou, ainda, estabelecer regime aberto nas situações de (c) pena aplicada abaixo dos 4 (quatro) anos, em caso de condenado reincidente" PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO SALO DE CARVALHO 3ª EDIÇÃO SARAIVA p.518/519.

De ver-se que o artigo 59, inciso III, preconiza que, a rigor, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ter como referencial as circunstâncias inculpidas no artigo 59, de molde que a reincidência, a rigor, não, necessariamente, conduz ao regime mais gravoso.

Demais disso, a reincidência valorada sucessivamente, a rigor, acaba por resvalar no princípio ne bis in idem, porquanto, em casos tais, está sendo valorada em mais de uma ocasião para recrudescer a situação do réu.

De fato, como regra, desponta como desproporcional que um fato externo, pelo qual o réu já foi condenado, tendo ou estando cumprindo a sua pena, que, a rigor, em nada se relaciona com o fato imputado nestes autos, portanto, extratípico, importe em recrudesimento de sua situação em etapas diversas, como, verbi gratia, no procedimento de fixação da pena, análise de possibilidade de substituição da pena ou suspensão de sua execução, e estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena, cabendo rememorar que, ontologicamente, a reincidência sempre vem timbrada pelo Direito Penal do Autor, porquanto, em casos tais, o recrudesimento não decorre da responsabilização pelo fato penal que está sendo imputado ao réu no processo objeto de julgamento, ao reverso, as valorações negativas e o juízo de censura decorrem daquilo que é ou representa ser, despontando, assim, uma reprovação pelo estigma.

Por sua vez, não se tratando de reincidência específica, a rigor, nada há a interditar a fixação do regime mais brando.

Deveras, calha ponderar, por oportuno, que, em verdade, se, diante da ausência de reincidência específica, o Código Penal, a rigor, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em uma análise sistêmica, que deve servir de linha guia para a interpretação de toda tessitura normativa do Código Penal, tratando-se de norma penal mais benéfica, não havendo reincidência específica, diante de circunstâncias judiciais que despontem como predominantemente como favoráveis, e, observando-se, por sua vez, o quantum da pena fixado, nada obsta a não fixação do regime fechado, o qual deve ser sempre excepcional, diante de todas as consequências dessocializadoras e estigmatizantes do cárcere.

Deveras, nesse sentido vem despontando a jurisprudência de escol:

A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados. STJ. 3ª Seção. AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/08/2021 (Info 706).

A reincidência específica tratada no art. 44, § 3º, do Código Penal somente se aplica quando forem idênticos, e não apenas de mesma espécie, os crimes praticados.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

A interpretação que as duas Turmas criminais do STJ dão ao art. 44, § 3º, do CP, conclui que a reincidência em crimes da mesma espécie, ainda que não seja no mesmo crime, obsta por completo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fica prejudicado, assim, o debate quanto à suficiência da pena substitutiva, porque a reincidência específica torna desnecessário aferir se a substituição é ou não socialmente recomendável.

Feita essa consideração, a questão que se apresenta pode ser sintetizada nos seguintes termos: para os fins da reincidência específica basta que o réu já tenha sido condenado por crime da mesma espécie, ou somente a condenação pelo mesmo crime impede a substituição da pena? A razão está com a última corrente.

O art. 44, § 3º, do CP, excepciona o requisito da primariedade para a substituição da pena privativa de liberdade com a seguinte redação: "Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] II - o réu não for reincidente em crime doloso; [...] § 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime".

De imediato, o princípio da vedação à analogia in malam partem nos recomenda que não seja ampliado o conceito de "mesmo crime". Toda atividade interpretativa parte da linguagem adotada no texto normativo, a qual, apesar da ocasional fluidez ou vagueza de seus termos, tem limites semânticos intransponíveis. Existe, afinal, uma distinção de significado entre "mesmo crime" e "crimes de mesma espécie"; se o legislador, no particular dispositivo legal em comento, optou pela primeira expressão, sua escolha democrática deve ser respeitada.

É verdade que, em sede doutrinária, não é unânime o conceito de reincidência específica, havendo quem a entenda configurada "se o crime anterior e o posterior forem os mesmos" ou, contrariamente, "quando os dois crimes praticados pelo condenado são da mesma espécie". Esta última definição está em sintonia com o art. 83, V, do CP, que proíbe o livramento condicional para o reincidente específico em crime hediondo - ou seja, quando a reincidência se operar entre delitos daquela espécie.

Também no art. 112, VII, da LEP, com as recentes modificações da Lei n. 13.964/2019, o conceito de reincidência específica está atrelado à natureza (hedionda, no caso desse dispositivo) dos delitos, e não à identidade entre os tipos penais em que previstos.

Por isso, se o art. 44, § 3º, do CP vedasse a substituição da pena reclusiva nos casos de reincidência específica, seria mesmo defensável a ideia de que o novo cometimento de crime da mesma espécie obstaría o benefício legal, em uma interpretação sistemática do CP e da LEP. Não foi isso, porém, que fez o legislador: com o uso da expressão "mesmo crime" - ao invés de "reincidência específica" -, criou-se no texto legal uma delimitação linguística que não pode ser ignorada.

Pode-se argumentar, é claro, que a utilização de conceitos distintos de reincidência específica (um para a substituição da pena privativa de liberdade, outro para o livramento condicional e a progressão de regime) prejudicaria a coerência interna da legislação penal. Essa realidade, aliás, é de conhecimento de todos que com ela operamos diariamente: os dois principais diplomas legislativos que esta Terceira Seção é chamada a interpretar - o CP e o CPP -, ambos octogenários, encontram-se defasados, repletos de cortes e alterados de forma pouco sistemática ao longo das décadas.

É possível ver, também, outro fator relevante em favor da interpretação que hoje prevalece, neste STJ, sobre o art. 44, § 3º, do CP.

Pela redação do dispositivo, há situações em que a progressão criminosa, com a prática de um delito mais grave, premia o agente com a substituição, enquanto o cometimento de dois crimes mais leves a proíbe. Por exemplo: o réu reincidente pela

prática de dois crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) não terá direito à substituição da pena, porquanto aplicável a vedação absoluta contida no art. 44, § 3º, do CP. De outro lado, se o segundo crime for de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), o réu pode fazer jus à substituição, se a pena não ultrapassar 4 anos de reclusão. Em outras palavras, o cometimento de um segundo crime mais grave poderia, em tese, ser mais favorável ao acusado, em possível violação ao princípio constitucional da isonomia.

Essa contradição é